

1508764-96.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181465/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25954957 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2181465 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK GIOVANNI DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508764-96.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181465/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25954957 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2181465 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK GIOVANNI DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JOÃO VICTOR DONATO e PATRICK GIOVANNI DOS SANTOS, estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificados às fls. 219 (João) e 221 (Patrick), os réus apresentaram resposta às fls. 222/238 (João) e fls. 239/241 (Patrick).

A denúncia foi recebida em 8 de setembro de 2022 (fls. 242/243) e os réus foram citados às fls. 227 (João) e 291 (Patrick).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 293 e 329).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 329).

As defesas postularam a absolvição, face a insuficiência de provas e, subsidiariamente, teceram considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 329).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), fotografias (fls. 35/43 e 79/86), laudos periciais (fls. 147/154 e 155/158), informação (fls. 162/163), além da prova oral.

A autoria também é certa.

Em juízo, João Victor rechaçou a acusação. Disse que foi convidado por Patrick para um jogo de futebol em Pouso Alegre (onde estavam várias pessoas, inclusive seu irmão) e, ao retornarem, foram abordados por uma viatura. Ignoraram o sinal de parada por estarem sem habilitação e serem recém egressos do sistema prisional e, no trajeto, dispensou uma lata de cerveja que estava em poder de Patrick. Durante a abordagem, os policiais proferiam ameaças e agressões. Informou-lhes que o objeto dispensado seria uma latinha. Na sequência, várias viaturas saíram e, ao retornarem, os milicianos disseram que haviam encontrado drogas, cuja propriedade nega. Confrontado acerca da versão apresentada em solo policial, disse que apenas pegou carona de volta com Patrick e que se equivocou ao narrar os fatos em juízo. Negou ter atribuído, informalmente, a posse da droga a Patrick ou que a fuga tenha sido em alta velocidade. Aduziu que os vizinhos se aproximaram do local da abordagem, dada a truculência da ação policial, todavia ninguém concordou em ser testemunha. O policial militar Marcelo sempre o abordou de maneira truculenta.

O réu Patrick negou os fatos. Alegou que, após um jogo de futebol no distrito de Pouso Alegre, ofereceu carona a João Victor para retornar a Jaú. Durante o trajeto, como uma viatura policial emitiu sinal de parada, entregou uma latinha de cerveja a João Victor, que dispensou o referido objeto. Após estacionar o veículo, obedeceu às instruções dos policiais, que agiram de maneira violenta. Questionado por eles, informou que o objeto dispensado era uma lata de cerveja. Negou a propriedade da droga exibida pelos policiais ou que os conhecesse de antemão.

O policial militar Gilmar relatou ter tomado conhecimento de denúncias irradiadas pela viatura de Bariri, via COPOM, de que ocupantes de um veículo GM Corsa branco estavam seguindo de Bariri a Jaú transportando drogas. Assim, visualizou o veículo dos réus e emitiu sinal de parada com sinais luminosos e sonoros, que não foram obedecidos. Durante a fuga, seu colega Marcelo observou que os ocupantes se desfizeram de um pacote às margens da rodovia. Realizou a abordagem e os réus ofereceram resistência, havendo a necessidade do uso de força para contê-los e algemá-los, pois eles estavam muito alterados e se negavam oferecer as mãos para tanto. Após a abordagem, permaneceu na contenção, enquanto seu colega, PM Marcelo, procedeu a diligências com o escopo de localizar o pacote dispensado pelos acusados, que foi encontrado nas proximidades de um ferro-velho. Posteriormente, verificou tratar-se de cocaína. Indagados no local, os acusados acusaram-se mutuamente. A viatura policial estava praticamente emparelhada ao carro dos réus durante a perseguição. O pacote foi arremessado na grama sem impacto suficiente para que rompesse. Não conhecia os réus anteriormente.

O PM Marcelo confirmou a narrativa de seu colega e afirmou ter visto o pacote sendo arremessado pelo vidro do passageiro (João Victor), quando o carro se aproximou do acostamento e reduziu a velocidade. Disse que retornou ao local e encontrou o objeto dispensado, que se tratava de cocaína. Aduziu que já havia abordado João Victor anteriormente em locais conhecidos pela prática de tráfico.

A despeito da negativa dos réus, as provas são suficientes para comprovação do crime que lhes foi imputado.

Cumpra desde logo observar que inexistente vedação legal à notícia anônima de crime. Como se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela. E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão dos réus, mas a apreensão de significativa quantidade de entorpecente (fls. 30/31), que foi arremessada por eles durante a fuga, tudo a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

Os réus apresentaram versões destoantes em solo policial e em juízo. Na primeira vez em que foram ouvidos, ambos afirmaram que estavam em Pouso Alegre (visitando familiares ou um colega) e se encontraram ao acaso, ao que Patrick ofertou uma carona a João Victor. Já sob o crivo do contraditório, alteraram a sobredita versão e disseram que estavam participando de um jogo de futebol e decidiram retornar juntos a Jaú. João Victor chegou a mencionar em juízo ter ido junto com Patrick até Pouso Alegre, todavia, confrontado acerca da referida narrativa, disse ter se equivocado e alegou que se encontraram no local.

Nenhum deles mencionou em solo policial que o objeto arremessado teria sido uma lata de cerveja e limitaram-se a negar a propriedade do entorpecente exibido. Patrick afirmou naquela ocasião que os vidros do carro estavam fechados, o que destoava da sua assertiva judicial quanto à dispensa da lata pelo passageiro.

No mais, durante seu interrogatório judicial, João Victor admitiu ter empreendido fuga e apresentou justificativa para tanto, mas perante a autoridade policial mencionou não ter entendido que se tratava de uma ordem de parada (fls. 8).

Quando ouvido pela primeira vez, Patrick alegou injustiças sofridas no passado como motivo para não atender ao sinal de parada emitido pelos policiais (fls. 7) e, sob o crivo do contraditório, alterou a versão e afirmou ter obedecido tal ordem e estacionado o veículo.

Referidas contradições e inconsistências enfraquecem as negativas dos réus, que, no mais, foram afastadas pelos coerentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares. E nenhum elemento concreto foi alegado capaz de afastar a credibilidade dos seus relatos.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição

de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Não é demais destacar que os acusados já foram condenados pela prática de furto em coautoria (Proc. 1500249-91.2021.8.26.0598 - fls. 199/200 e 201), o que reforça a inclinação de ambos para práticas ilícitas em conjunto.

No mais, o fato dos réus não terem sido surpreendidos no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que, como cediço, elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. E a grande quantidade de droga apreendida não deixa dúvida de que ela se destinava à entrega a terceiros.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor dos acusados, que não trouxeram elementos a infirmá-lo. E, ainda que eles também sejam usuários, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Assim, a condenação é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

JOÃO VICTOR DONATO

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade de cocaína apreendida (fls. 30/31), pelo que fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (por duas condenações, uma delas específica, fls. 201 - Proc. 1500249-91.2021.8.26.0598 e fls. 201/202 - Proc. 0000062-65.2018.8.26.0598). Assim, majoro a reprimenda de 1/3 para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu enseja o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

PATRICK GIOVANNI DOS SANTOS

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade de cocaína apreendida (fls. 30/31), pelo que fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, por duas condenações, (fls. 198 - Proc. 0000563-34.2018.8.26.0302 e fls. 199/200 - Proc. 1500249-91.2021.8.26.0598). Assim, majoro a reprimenda de $\frac{1}{4}$ para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu enseja o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer à lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a

liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal - art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o réu JOÃO VICTOR DONATO à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no mínimo legal, e PATRICK GIOVANNI DOS SANTOS à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime

inicial fechado, e ao pagamento de 728 dias-multa, no mínimo legal.

Os acusados responderam ao processo presos e agora, com maior razão, não poderão apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontram.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do veículo apreendido, pois utilizado na prática delitiva, e determino a oportuna restituição aos réus dos demais bens lícitos apreendidos. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA